

0038003-39.2021.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021.0080810 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MORAIS SANTANA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/03/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 15 de março de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0038003-39.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021.0080810 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO MORAIS SANTANA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/03/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 15 de março de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). DANIELA MOISÉS DA SILVEIRA FAVARO, o(a) Dr(a). ANTONIO CARLOS RINALDI – OAB/SP 140.063, defensor(a) do ré(u) preso DIEGO MORAIS SANTANA (apresentado), APF VLADIR – matrícula 14844 – lotado em SR/PF/SP, ANDRESSA DOS SANTOS DE MELO, ERICA CRISTINE MACIEL e DENISE FERNANDES PINTO. Ausente a testemunha FRANCISCO MARCULINO SILVA. Assim, foram ouvidos: VLADIR e ANDRESSA DOS SANTOS DE MELO (testemunhas de acusação) e 02 testemunhas de Defesa, ERICA CRISTINE MACIEL e DENISE FERNANDES PINTO, (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha ausente FRANCISCO MARCULINO SILVA, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após conversar com sua Defesa, o(a) ré(u) foi interrogado(a) pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que: Meritíssimo(a) Juiz(a), o réu DIEGO MORAIS SANTANA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 5 de novembro de 2021, na Rua João Lanhoso, n.º 232, Heliópolis, nesta capital, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 3,5kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 106). Citado (fls. 143), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 111/115). Na data de hoje, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. É o breve relatório. A denúncia deve ser julgada procedente. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e documentos que o acompanha, especialmente o auto de exibição e apreensão (fls. 25), laudo pericial de constatação provisória (fls. 39/41) e laudo químico-toxicológico (fls. 86/90), bem como pela prova oral produzida. A autoria é indubitosa. Está provado nos autos que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado guardava as drogas acima descritas, com o fim de entregá-las ao consumo de terceiros. Policiais federais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra o denunciado, se dirigiram à residência dele, situada no local dos fatos. Referidos agentes públicos, munidos do mandado, ingressaram no local, oportunidade em que o denunciado se dirigiu ao banheiro da casa, onde tentou se desfazer do entorpecente, jogando-o no vaso sanitário. Entretanto, os policiais federais conseguiram abordar e impedir o denunciado, localizando a totalidade das drogas apreendidas. No interior do imóvel também foi encontrada uma balança de precisão. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial, onde confessou a prática delitiva (fls. 19). Em Juízo, DIEGO disse que realmente estava guardando drogas. Havia mandado de busca e apreensão pelo crime de uso de cartão fraudado. Disse que estava devendo dinheiro para agiota e não conseguia pagar em razão da pandemia. Pediu dinheiro para um amigo, que lhe entregou as drogas para ele as guardasse. O policial federal Vladir disse que ingressaram na residência de Diego, após a entrada da equipe tática, sendo que o réu já estava dominado. Assim que ingressou na residência, foi realizar a vistoria. As drogas estavam no banheiro, em sacolas plásticas. O réu estava tentando se desfazer da cocaína, jogando na privada. O réu residia com a esposa e com dois filhos no local. A busca e apreensão decorreu de uma investigação da caixa econômica federal. A testemunha Andressa dos Santos de Melo disse que os policiais disseram que, se DIEGO não assumisse a droga, ambos seriam presos. Não sabia que havia drogas dentro da residência. Considerando todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório pré-processual restou suficientemente comprovado em juízo, sendo absolutamente apto a lastrear a sentença condenatória. Destaca-se que gozam de importante credibilidade probatória os depoimentos dos agentes públicos, não

havendo qualquer indício de que teriam razões para imputar à ré crime de forma injusta. Até porque nada levantou a Defesa a respeito de motivos pelos quais teriam que ser as palavras dos policiais recebidas com reservas. Insta ressaltar o entendimento consolidado do STJ no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 408808/PE HABEAS CORPUS 2017/0176479-0, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, em 03.10.2017), sendo que “inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova” (STJ, HC 418529 / SP HABEAS CORPUS 2017/0251727-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17/04/2018 A prova, pois, é robusta e autoriza a convicção de responsabilidade do acusado, nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, tem-se que o réu é reincidente específico (fls. 101/104), o que deve ser considerado na fase adequada. Contudo, a pena-base deve ser fixada além do patamar mínimo legal, em claro atendimento aos comandos legislativos postos no art. 42, da Lei nº 10.343/06, em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas e do poder vulnerante das substâncias. Repise-se que o réu foi encontrado em posse de relevante quantidade de entorpecentes – 3,5kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína. Como é cediço, apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Habeas Corpus Criminal nº 2167456-43.2020.8.26.0000 – Voto nº 5 26/10/2017), de modo que a quantidade de droga apreendida poderia atingir inúmeros consumidores. Sem prejuízo, anoto a prejudicialidade específica da cocaína. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, foram consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida (21,366kg de cocaína) para elevar a reprimenda básica, entendimento que se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 2. Não se pode considerar ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 516768 / RO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0178402-2, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 01.10.2019). Na segunda fase, tem-se a reincidência específica em tráfico (a pena do acusado somente foi extinta e 30 de junho de 2016) e que o réu confessou a prática do crime. Na terceira fase, nada a considerar. Anoto, contudo, que o réu não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, como já explicitado, foi encontrado em poder de relevante variedade e quantidade de entorpecentes. A melhor interpretação do artigo 33, §4º, é a de que o dispositivo é aplicável apenas ao chamado “traficante eventual” ou ao “traficante de primeira viagem” (Rel. Des. MARCOS ZANUZZI, TJSP/5ª Câmara, Apelação Criminal nº 1.098.7683.3/9 Limeira v.u. j. em 22.11.2007), o que, por óbvio, não se verifica no caso em exame. Nesse sentido: “(...) Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista n §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas(...)”. (STJ, HC 373523 / SP HABEAS CORPUS 2016/0259708-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 14.08.2018). E não prospera a tese da ocorrência de bis in idem ao considerar a quantidade e variedade de drogas para fins de aumento da pena-base e para o

afastamento da referida causa de diminuição de pena. Veja-se: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO(...). III - Outrossim, é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes". (HC 424437 / RJ HABEAS CORPUS 2017/0292125-2, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, em 06.02.2018). Com relação ao regime de cumprimento da pena, deverá ser estabelecido o fechado, sobretudo diante da gravidade concreta do crime praticado. Além do mais, incidiu o acusado em crime constitucionalmente equiparado a hediondo (artigo 5º, XLII, da Constituição Federal), a demonstrar que o Constituinte, ao assim prevê-lo, quis inserir na mais alta norma do ordenamento pátrio a previsão de tratamento mais enérgico àqueles que incorrem na referida conduta. Trata-se, assim, de evidente mandamento constitucional de natureza penal, consolidando a ideia de proteção eficiente a bens jurídicos consagrados pelo Direito pátrio. A concessão de tratamento mais benevolente – seja por regimes que não o fechado, seja pela concessão de penas restritivas de direitos – àquele que difunde inúmeros prejuízos à saúde pública, causando inestimáveis danos não somente à rede de atendimento, mas também aos núcleos sociais diversos, ofende frontalmente a dignidade da pessoa humana. Refletindo os argumentos expostos, o elucidador precedente deste Tribunal de Justiça: "(...) a fixação de regime mais brando não atenderia aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, levando-se em conta, como já mencionado, a personalidade do réu voltada ao delito, as circunstâncias e gravidade do crime, e o total de pena imposto. De modo contrário, injusta seria a situação daquele que pratica conduta menos gravosa, com condenação a pena mais branda, sujeito ao mesmo regime prisional daqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados. Se assim não fosse, não teria sentido outro regime a ser fixado. O legislador, o que se observa na própria Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII), ao tratar o traficante de drogas com o regime necessário, até pelo fato de o delito ser equiparado a hediondo, negou-lhe vários benefícios que a outras espécies de criminosos seriam cabíveis (...). Portanto, seria contraditório que, condenados, esses infratores recebessem pena alternativa ou cumprissem as reprimendas em regime diverso do fechado, não havendo que se falar em inconstitucionalidade." (TJSP; Apelação 0019747-87.2017.8.26.0050; Relator: Marco Antonio Marques da Silva; 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; j. 22/02/2018). Por fim, pelas mesmas razões já expostas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal, tratando-se de medida que é não socialmente recomendável no caso concreto. As circunstâncias em que cometido o delito revelam, inequivocamente, que a substituição não seria suficiente para atingir as finalidades de retribuição e prevenção da reprimenda. Não se pode olvidar, ainda, que se trata de um delito equiparado a hediondo e, portanto, de maior repugnância, gravidade e lesividade à sociedade. Destaca-se o entendimento consolidado no STJ: "TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, à natureza e à diversidade da droga apreendida é motivação suficiente a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias em que ocorreu o delito, em especial o número de porções, e a nocividade do entorpecente apreendido, denotam que a medida

substitutiva não se mostra socialmente recomendável, sendo, portanto, legítimo impedir a permuta pretendida pelo agravante (...)" (AgRg no AREsp 507029 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0092856-2, Min. Rel. Jorge Mussi, 5ª Turma, em 10.10.2017). Ante o exposto, requeiro a PROCEDÊNCIA da ação penal, para condenar o réu DIEGO MORAIS SANTANA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.0(a) Dr(a). Defensor(a) se manifestou em sede de debates orais, gravados por áudio e vídeo. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença:

"Vistos. DIEGO MORAIS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 05 de novembro de 2021, na Rua João Lanhoso, nº 232, Heliópolis, nesta cidade e comarca de São Paulo, teria guardado e mantido em depósito, para fins de tráfico, 3,5kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 15/12/2021 (fls. 106/109), advindo resposta à acusação (fls. 111/117). O feito prossegue, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (fl. 118). Encerrada a instrução, o Ministério Público postula a procedência da ação penal e, na dosimetria, seja considerada a reincidência específica, pena acima do mínimo legal em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e vedação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A i. Defesa, por sua vez, requereu seja considerado que o acusado, a despeito de condenação antiga, encontra-se totalmente ressocializado, não tendo por hábito a prática de crimes. O comportamento fora adotado de forma impensada em virtude da duríssima situação financeira enfrentada, notadamente pela Pandemia COVID19, o que deve ser considerado como atenuante genérica. Encontra-se arrependido, tanto que confessou integral e voluntariamente a prática do crime em evidência. Relatei sumariamente. Fundamento e DECIDO. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 10), termo de apreensão (fl. 25), laudo pericial definitivo (fls. 86/90; v. fl. 108, item '6'), bem como depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Inconteste a autoria. Com efeito. Interrogado, o réu confessou a prática do crime reportado na denúncia. Disse que estava guardando o material para uma pessoa do bairro que iria lhe ajudar a pagar uma dívida contraída junto a um agiota. Sua esposa nada sabia acerca dos fatos. No momento da prisão, se assustou e tentou jogar o material pelo vaso sanitário, não logrando êxito. Possuía dois comércios e, devido à crise, teve de fechar um e o remanescente não lhe propiciava renda como outrora, especialmente em virtude da pandemia COVID-19. Contraiu inúmeras dívidas, inclusive com agiota, que aparecia constantemente em sua casa para cobrá-lo. Procurou, então, ajuda com um amigo do bairro, pessoa que garantiu ajudá-lo financeiramente. Embora não tenha ficado claro se se tratava de contrapartida, aceitou o pedido desse 'amigo' para guardar em sua casa uma caixa contendo a droga, a qual seria restituída na semana seguinte, quando então o ajudaria a pagar o agiota. A confissão encontra total amparo nos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Vladir Arienzo Júnior, policial federal, esclareceu que a prisão se deu de forma fortuita, em meio ao cumprimento de mandado de busca domiciliar decorrente de investigação policial sobre fraude perpetrada em face da Caixa Econômica Federal. Primeiro, ingressou no imóvel a equipe tática da polícia federal, dominando o ambiente. Na sequência, com o réu já custodiado, o depoente entrou no imóvel e procedeu à varredura do local, cômodo a cômodo. No banheiro, encontrou algumas sacolas plásticas com um pó branco, constatando tratar-se de cocaína. Pelo que soube da equipe tática, o réu tentava se desfazer do material pelo vaso sanitário. No local, DIEGO residia com a esposa e dois filhos. Confirmou ter assinado o termo de depoimento, com as informações de praxe. Andressa dos Santos de Melo, companheira do réu, sem compromisso formal, afirmou terem levado seu esposo para o quarto dos fundos. Ouviu do Delegado ser necessário falar que a droga era do acusado porque, caso não assumisse, levaria ambos à Delegacia. O Delegado mencionou que os filhos seriam encaminhados ao Conselho Tutelar. Desconhecia a existência das drogas. Por fim, Denise Fernandes Pinto e Erica Cristine Bastos Maciel, testemunhas arroladas pela i. Defesa, nada declararam acerca dos fatos em julgamento, noticiando tão-somente a surpresa ao tomarem conhecimento da prisão de DIEGO. Confirmam tratar-se de pessoa trabalhadora, sem envolvimento com o crime, que possuía estabelecimento comercial

no bairro onde residem. Não vislumbro, de proêmio, nenhuma irregularidade na busca e apreensão efetivada nos autos, tampouco acerca de eventual fala do Delegado de que levaria ambos os consortes à Delegacia caso não houvesse a indicação do responsável pela prisão. Afinal, DIEGO e Andressa residiam sob o mesmo teto. Quanto a chamar o Conselho Tutelar, tratar-se-ia de providência necessária, porquanto os Srs. Conselheiros são as autoridades responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, providenciando eventuais encaminhamentos dos filhos menores, notadamente à família extensa, em caso de prisão de ambos os genitores (art. 131 e seguintes da Lei nº 8.069/1990). As teses escapatórias igualmente não convencem: o acusado detinha ciência plena acerca das consequências do ilícito perpetrado. É certo que a Pandemia afligiu muitos trabalhadores, notadamente comerciantes, mas nem por isso justifica a prática de qualquer crime, a fortiori o tráfico de entorpecentes. Quanto ao agiota,

impende ressaltar que o acusado adotou o comportamento gerador da consequência que pretendia, agora, evitar, não podendo se valer do argumento para obter benefício legal ou isenção de pena, mormente sob o pretexto de estado de necessidade, inócurrenente na espécie. Presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, resta a quantificação da justa reprimenda. Considerando a elevada quantidade do material espúrio [3,5kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína], pelo princípio da proporcionalidade e à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 ('O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente') a pena base deve ser majorada em 3/5 (três quintos). Dessa forma, postergando a análise dos antecedentes para a terceira fase da dosimetria (o que evita arguição de bis in idem) nesta primeira fase chega-se a 8 (oito) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa. Na segunda fase, inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa. Até porque prevista, ordinariamente, como agravante, as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública em virtude da Pandemia COVID-19 não podem, por outro lado, se convolver em atenuante genérica (CP, art. 66). Seria, data venia, um contrassenso fazê-lo. A confissão merece ser computada (CP, art. 65, inciso III, alínea 'd'), mostrando sinceridade o relato do acusado. Reduzo a sanção, portanto, em 1/6 (um sexto). A pena chega a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na fase derradeira, aplica-se o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual '... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'. O réu é tecnicamente primário, porquanto passados 05 (cinco) anos do período depurador (a pena anteriormente aplicada fora declarada extinta em 30/03/2016, conforme fl. 103). Ostenta, porém, maus antecedentes. Vale registrar ser possível considerar a condenação anterior transitada em julgado como maus antecedentes, ainda que passados 05 (cinco) anos da sua extinção. Invoco, como fundamento, o precedente a seguir (TEMA 150/STF): 'EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte

tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal' (RE 593.818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11- 2020 PUBLIC 23-11-2020). Todavia, não é possível igualar as consequências da reincidência à dos maus antecedentes: o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas vale-se de termo objetivo quando alude à primariedade, porém, quando se reporta aos antecedentes criminais, confere certa liberdade interpretativa ao julgador para fins de aferi-los como 'bons' ou 'maus'. Também é imperioso destacar que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, para fins de aplicação, ou não, do redutor, devem ser analisadas cum grano salis. Há situações extremas nas quais a enorme quantidade de drogas encontrada permitiria uma conclusão juridicamente segura no sentido de que a traficância se dá em grande escala. Não é esse, ao que tudo indica, o caso dos autos. Dessa forma, a situação do réu caracteriza-se mais como de traficância eventual (guardou o material para um amigo, exercendo outra atividade econômica como meio de vida), afastando a tese de dedicar-se a atividade ou organização criminosa. Embora exista divergência jurisprudencial quanto ao tema, comungo do entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, para o qual 'a quantidade de drogas, mesmo volumosa, no campo abstrato, não impede a aplicação do redutor, impondo-se a diminuição da pena. Não se pode deduzir que, em tese, por haver quantidade expressiva, o acusado está envolvido com o crime organizado ou se dedique a atividades criminosas, razão pela qual impediria o redutor. Excepcionalmente, no entanto, uma quantidade anormal de drogas pode indicar a participação em grupo criminoso e essa circunstância deve resultar das provas inerentes ao processo. Enfim, cada caso é um caso' (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 1, 14ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 409). Considerando, dessa forma, que o réu ostenta maus antecedentes, porém relacionados a fatos antigos, consoante se infere da FA de fls. 101/104 (o processo criminal é de 2008; autos nº 10675/2008), entendo fazer jus ao benefício legal, contudo em patamar inferior, in casu, 1/3 (um terço). Nesse diapasão, torno definitiva a sanção equipolente a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa. Considerando não haver prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal). O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto, em face do tempo de pena corporal, acatando o disposto no art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Repressor. O período de custódia cautelar não é suficiente à progressão imediata de regime. Prejudicada no caso em apreço a incidência do art. 387, §2º, do CPP. Inviável, pela quantidade da reprimenda, a substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, inciso I) ou sursis (CP, art. 77. caput). CONCLUSÃO. Diante de todo o exposto, julgo procedente a ação penal formulada em face de DIEGO MORAIS SANTANA, qualificado nos autos. Em consequência, condeno-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicial semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então. Não localizei numerário apreendido. Ressalvada a manutenção de amostras para pelo menos mais dois eventuais exames de contraprova, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas. Autorizo a destruição da balança de medição (fl. 25), instrumento utilizado para a consecução do delito. O réu arcará com as custas previstas no art. 4º, §9º, alínea 'a', da Lei Estadual nº 11.608/2003. Se ausente a interposição de recurso pelas partes, expeça-se guia de recolhimento definitiva, com a urgência necessária. Oportunamente, providenciem-se as comunicações de estilo, notadamente as previstas nos artigos 393, inciso V e 398, inciso II (TRE); ambos das NJCGJ. Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, proceda-se na forma do seu art. 480. Registre-se. Intimem-se". Após lida a sentença, o Ministério Público, a Defesa

e o(a) ré(u) manifestaram interesse em não recorrer. Com efeito, o(a) ré(u) sai devidamente intimado(a) da condenação e do pagamento da multa, cujo valor deverá ser solicitado pelo réu por email ao cartório (sp10cr@tjsp.jus.br) no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual começará a fluir o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, sob pena de ter o seu nome inscrito na dívida ativa do Estado. Ainda, caso o pagamento da referida multa não seja efetuado no prazo de 10 dias do transito em julgado da presente decisão, expeçam-se certidões e ofício à Procuradoria da Secretaria da Fazenda - Setor - EX_CI, encaminhando-se as peças necessárias para inscrição da dívida. Após revisados os autos, ao arquivo. Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário).

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 17 de março de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.